

1500734-06.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Indagado, o acusado admitiu a prática do tráfico. Havia, salvo engano, noventa e três reais com ele. O réu tinha também consigo duas porções de maconha e, no local onde ele mexeu, havia outras duas porções de maconha e também crack. Ao todo, salvo engano, eram cinco porções de entorpecentes. O local é conhecido como ponto de tráfico. Durante a abordagem, o réu admitiu que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500734-06.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500734-06.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2179626/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 18852693 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 3421/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2179626 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2179626 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 3421/21/050 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GIOVANE HENRIQUE AMORIM LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

GIOVANI HENRIQUE AMORIM LOPES foi dado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11343/2006, porque, no dia 03 de julho de 2021, por volta de 11:30 h, na avenida Cruzeiro do Sul, esquina com Rua Oito, no Jardim Country Club, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção de maconha com peso de 2,30 gramas, duas porções de maconha com peso de 2,68 gramas, duas porções de crack com peso de 0,43 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado (fls. 96), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 102/103.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 30 de agosto de 2021 (fls. 104/106). Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 128 - audiovisual; e fls. 150/168 - audiovisual e transcrição).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 184/187).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 195/233, alegando que: 1)- interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime; 2)- surpreende que os policiais não tenham memorizado a placa do automóvel que estava a cerca de dez metros deles; 3)- somente com a oitiva do motorista seria possível saber se o réu estava ali para comprar drogas ou não, pois a quantidade apreendida era compatível com sua versão de ser apenas usuário; 4)- os depoimentos dos policiais não são suficientes para a condenação; 5)- eventualmente, a conduta deve ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas; 6)- ainda eventualmente, deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11343/2006, deve ser fixado o regime inicial aberto e substituída a pena corporal por alternativas. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta, a aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão de fls. 12 e pelo laudo pericial de fls. 66/70 (uma porção de maconha com peso de 2,30 gramas; duas porções de maconha com peso de 2,68 gramas; e duas porções de crack com peso de 0,43 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao réu.

Ouvido na polícia, ele confessou a prática do tráfico, bem como admitiu a posse da droga e do dinheiro, acrescentando que este último é produto do crime. (fls. 08).

Em juízo, a testemunha Eduardo Moreno Barbosa, policial militar, afirmou que, na data em questão, estava em patrulhamento pelo bairro Ferradura Mirim. Na rua Oito, deparou-se com o réu agachado, mexendo numa moita. Ele entregou algo ao condutor de um veículo. O motorista se evadiu logo após perceber a presença da viatura. O réu também tentou se evadir, mas foi abordado. Durante revista pessoal, foram encontrados em seu bolso traseiro entorpecente e dinheiro. Depois, feita busca na moita, foi achado mais um pouco de droga. Indagado, o acusado admitiu a prática do tráfico. Havia, salvo engano, noventa e três reais com ele. O réu tinha também consigo duas porções de maconha e, no local onde ele mexeu, havia outras duas porções de maconha e também crack. Ao todo, salvo engano, eram cinco porções de entorpecentes. O local é conhecido como ponto de tráfico. Durante a abordagem, o réu admitiu que o dinheiro era fruto do comércio de drogas. Na delegacia, porém, negou. Não se lembra se ele mencionou estar em liberdade provisória. Recorda-se que o acusado já havia sido preso por tráfico.

A testemunha Ícaro de Melo Roque, também policial militar, relatou ter avistado o réu abaixando numa moita e indo em direção a um veículo. O condutor do automóvel, ao notar a presença da polícia, evadiu-se. O acusado colocou algo no bolso, tentou correr e foi abordado. Na revista, encontraram-se uma porção de maconha e um valor em dinheiro no bolso dele. Naquela moita, havia mais entorpecente. Indagado, o réu admitiu que realizava o tráfico. O numerário se apresentava em várias notas "picadas". O local é conhecido pela prática do tráfico. O réu estava mexendo na moita antes de se dirigir ao carro. Na moita, salvo engano, havia duas pedras de crack e duas trouxinhas de maconha. No momento que o veículo se evadiu, estava a cerca de dez metros dele e do acusado. Não foi possível anotar a placa do automóvel, porque preferiu-se abordar o réu e por se ter noção de que o motorista estaria adquirindo droga (fls. 157/161).

Interrogado em juízo, o réu declarou ter ido ao local para comprar droga para seu consumo. Estava com o motorista do veículo, que era um "Uber". Ele viu a viatura e o deixou para trás. Foi detido na biqueira. Na delegacia, confessou o tráfico porque foi ameaçado. Mora a duas quadras do local. Os policiais lhe disseram que, se não segurasse a droga, iriam em sua casa e prenderiam sua mulher. Já havia sido

preso anteriormente por tráfico. Tinha consigo R\$ 115,00, fruto de valor de pensão que o seu tio havia lhe dado. Como seu pai não tinha condições, o tio o ajudava todos os meses. O traficante correu. Em sua mão, havia duas balinhas de crack e três de maconha, a par de noventa reais, que sobrou de troco. (fls. 163/168). Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa que sustentam o contrário.

É certo que o réu, quando interrogado em juízo, negou a prática do tráfico. A negativa, no entanto, soa como forma natural de afastar a responsabilidade criminal e suas consequências, e não pode ser admitida, porque em contradição com o conjunto probatório.

Veja-se que, em solo policial, o acusado confessou a prática do tráfico.

A confissão extrajudicial é relevante elemento de convicção.

Nesse sentido:

“É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil.” (TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

No caso, a confissão extrajudicial restou corroborada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares colhidos em juízo, segundo os quais o réu foi inicialmente visto abaixado, mexendo numa moita, e depois dirigindo-se até um veículo, cujo condutor se evadiu ao notar a presença da viatura.

Ainda de acordo com os policiais, o réu portava droga e dinheiro, ao passo que, naquela moita, havia outras porções de entorpecentes.

Não vinga o argumento de que os depoimentos dos policiais, quando isolados, não se prestam à condenação.

Primeiro, porque, como visto, no caso, tais depoimentos não estão isolados, já que foram no mesmo sentido da confissão do acusado em solo policial.

Segundo, porque dois servidores públicos não iriam à polícia e também não viriam em juízo, para afirmar fatos inverídicos em detrimento de pessoa que sequer conheciam, correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e até criminalmente pela falsa acusação.

No aspecto considerado, acrescente-se que a defesa e o réu não trouxeram qualquer dado específico a apontar que os policiais teriam algum motivo para falsear a verdade em prejuízo dele.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.” (RT 610/369).

Em igual sentido:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 – São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

Por outro lado, a narrativa do acusado, no sentido de que foi levado ao local por

um motorista de aplicativo ("Uber") para apenas adquirir droga não convence. Isto porque, embora ele tenha afirmado que o traficante correu ao notar a aproximação da viatura policial, os policiais militares que serviram de testemunhas sequer foram indagados de forma específica se viram alguém correndo. Outrossim, se aquele carro era realmente conduzido por um motorista de "Uber", a demonstração do alegado seria muito fácil, na medida em que a empresa em questão tem o registro dos chamados e das corridas de seus colaboradores. Ademais, se surpreende que os policiais não tenham memorizado a placa do automóvel, maior surpresa ainda causa a circunstância de o próprio réu não a ter informado para que sua narrativa pudesse ter sido confirmada (na medida em que a contratação do transporte teria se dado via aplicativo de celular por ninguém menos do que o acusado).

A inércia da defesa, no ponto em questão, é sintomática.

Prosseguindo, embora o acusado tenha declarado ter recebido a quantia de cento e quinze reais de um tio, igualmente nada comprovou a respeito.

Lembre-se, ainda uma vez, que a demonstração da afirmação em questão poderia também ter sido feita de forma muito fácil, bastando que o tio fosse arrolado como testemunha.

Por fim, e a evidenciar de forma cabal que o réu não estava ali para comprar entorpecente, e sim para vendê-lo, não se pode olvidar a circunstância de ele ter sido avistado inicialmente agachado, mexendo numa moita, antes de se dirigir até o veículo que se evadiu.

Trata-se da dinâmica própria e corriqueira do traficante no varejo que, ao invés de segurar todo o entorpecente consigo, guarda a maior parte em algum local nas proximidades para não gerar suspeitas, e não a de um usuário que apenas realiza rápido gesto de troca com o fornecedor.

Em suma, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas.

Ao contrário, a condenação do réu por tráfico é medida de justiça.

Passa-se à aplicação das penas.

O acusado não tem antecedentes criminais (fls. 39).

Diante disso, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

O acusado faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11343/2006.

As quantidades de drogas e de dinheiro apreendidas foram pequenas, não se podendo inferir, apenas a partir de tal circunstância, que se estaria diante de agente dedicado a atividade criminosa ou integrante de organização criminosa.

Por outro lado, é certo que o réu responde a outro processo por crime de tráfico, já com condenação em primeiro grau.

Este juízo vinha deixando de aplicar o privilégio para réus cujos processos em andamento indicassem dedicação a atividade criminosa, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e por entender ser necessário, a bem da segurança jurídica e do prestígio ao princípio da igualdade, seguir a orientação de Tribunais Superiores.

Ocorre, porém, que, no Supremo Tribunal Federal, a Segunda Turma tem entendimento em sentido contrário, ou seja, não é possível levar em conta processos ou inquéritos em andamento para fins de afastamento da causa de diminuição.

Nesse sentido:

"1.Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como Maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. 7.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como Maus antecedentes

decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria." (STF, Segunda Turma, Habeas Corpus 151.431/Minas Gerais, relator Ministro Gilmar Mendes).

Havendo, portanto, divergência nos Tribunais Superiores a respeito da questão, entende-se que o juízo de primeiro grau deve ter ampla liberdade para analisar o tema.

No caso, não houve trânsito em julgado de sentença condenatória no outro processo. Nessa conformidade, não se pode dizer que o réu se dedica a atividade criminosa, apenas em razão da notícia de estar respondendo a outro processo penal.

Do contrário, haveria ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Com efeito, se se considerar que a simples existência de inquérito ou ação penal em andamento impede a aplicação do privilégio, poder-se-ia ter a seguinte situação: o réu, a quem negada a redução de pena, suportaria a aplicação de, no mínimo, cinco anos de reclusão, passaria a cumpri-la em regime semiaberto e, posteriormente, viria a ser absolvido ou então condenado nas penas do artigo 28 da Lei Antidrogas no processo anterior.

Não há dúvida de que, em tal caso, teria ele suportado constrangimento ilegal e inconstitucional.

Logo, deve ser considerado cabível o privilégio.

Considerando, de resto, terem sido pequenas as quantidades de drogas e dinheiro encontradas em poder do acusado, reduz-se a pena na fração máxima de dois terços, resultando em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no julgamento do Habeas Corpus n. 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual os acusados começarão a cumprir a sanção.

Em se tratando de réu sem antecedentes criminais e que portava pequenas quantidades de drogas e de dinheiro, fixa-se o regime inicial aberto.

Levando em conta as mesmas circunstâncias judiciais favoráveis, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-

base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplicado redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Insistindo, na mesma decisão acima referida, o Ministro Gilmar Mendes também sustentou:

"Por fim, no que concerne à substituição da pena, ressalto, por oportuno, que o Plenário do STF, ao julgar o HC 97.256/RS, de relatoria do Ministro Aires Britto, decidiu ser inconstitucional o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, na parte em que vedava a possibilidade de substituição da pena, determinando o exame pelo juízo de origem do preenchimento dos requisitos legais para a referida conversão. Dessa forma, ante a declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', deve ser reconhecida, diante da avaliação do caso concreto, a possibilidade de concessão do benefício da substituição da pena, segundo os requisitos do art. 44 do CP." (Habeas Corpus n. 137458/SP).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Giovane Henrique Amorim Lopes como incurso nas penas do artigo 33, caput, e § 4º, da Lei n. 11343/2006, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Diante da pena imposta, expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.

Bauru, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA